

0087471-45.2016.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 7793/2016 -

98º Distrito Policial - Jardim Miriam, 886/2016 - 98º Distrito Policial - Jardim

Miriam

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL MARQUES DA SILVA

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0087471-45.2016.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0087471-45.2016.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 7793/2016 -

98º Distrito Policial - Jardim Miriam, 886/2016 - 98º Distrito Policial - Jardim

Miriam

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL MARQUES DA SILVA

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

RAFAEL MARQUES DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no

artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo a denúncia (fls. 01/02 e 77/78), no dia 19 de outubro de 2016, por volta das 01h50, na Rua dos Saburus, nº 34, Pedreira, nesta capital de São Paulo, trazia consigo 21 invólucros plásticos contendo cocaína (lacre nº 354513, peso total de 9,2g), 17 invólucros plásticos contendo crack (lacre nº 354513, peso total de 5,4g) e 54 invólucros plásticos contendo maconha (lacre nº 354513, peso total de 132,1g), sem autorização e em desacordo com determinação legal, para fins de tráfico.

Consta da denúncia que segundo se apurou, policiais militares, em patrulhamento pelo local, conhecido como ponto de venda de drogas, avistaram o denunciado, na entrada da viela, carregando um estojo nas mãos, o qual ameaçou correr ao avistar a viatura, todavia, foi abordado.

Relata a inicial que no estojo que ele carregava, os policiais localizaram as drogas acima mencionadas, além da quantia de R\$ 39,00 (trinta e nove reais).

Narra a exordial que quando foi indagado, o acusado confessou a prática do tráfico. Mas quando foi interrogado a fl. 08, permaneceu em silêncio.

Expõe a denúncia, por fim, que as circunstâncias que envolveram os fatos, ou seja, a quantidade e variedade de drogas encontradas com o denunciado, indicam que elas se destinavam ao comércio ilícito.

Em audiência de custódia, presidida aos 19 de outubro de 2016, a prisão em flagrante foi homologada e foi concedida liberdade provisória ao acusado, com aplicação de medida cautelar diversa, consistente em comparecimento bimestral em juízo, bem como recolhimento noturno (fls. 69/71).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 01 de dezembro de 2016 (fl. 94).

Não se logrou êxito na citação pessoal do acusado (fl. 99), razão pela qual foi determinada a sua citação por edital (fls. 110, 115 e 117/118).

Decorrido o prazo in albis, conforme manifestação ministerial (fl. 125), em 14 de novembro de 2017, foi suspenso o processo e o prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (fl. 127).

Sobreveio aos autos notícia de que o réu supostamente incorreu na prática de outro crime, na data de 26 de setembro de 2021 (fls. 135/143).

Assim, o acusado foi citado pelo aplicativo Microsoft Teams junto ao CDP Osasco II (fl. 149). Na sequência, a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação, requerendo, em suma, a rejeição da denúncia e/ou a absolvição sumária do acusado (fl. 153).

Aos 25 de fevereiro de 2022, foi retomado o curso do processo e do prazo prescricional. Em tempo, foi mantido o recebimento da denúncia oferecida e, na mesma oportunidade, foi designada audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento para o dia 21 de junho de 2022 (fls. 154/155).

O acusado foi intimado a comparecer à audiência supra designada (fl. 181).

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas as testemunhas e, em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, seguiram-se os debates finais. O Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada procedente, com a condenação do Réu, nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em suma, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, caso assim não se entenda, na remota hipótese de condenação, requer-se: a) a fixação de eventual pena no mínimo legal, pois o réu é primário, confessou a prática do delito em juízo, não ostenta antecedentes criminais e as demais circunstâncias judiciais lhe são amplamente favoráveis; b) a aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em seu grau máximo, diante da primariedade do réu e da ausência de comprovação de que se dedique ao tráfico ou de que faça parte de organizações criminosas para o mesmo fim, estando presentes, portanto, todos os requisitos legais; c) a outorga de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, diante da culpabilidade em tese atenuada do acusado e considerando que a mera gravidade em abstrato do delito não implica, necessariamente, em tratamento penal mais rigoroso, conforme entendimento pacífico dos Tribunais Superiores; d) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, pois ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A conduta imputada ao réu subsume-se ao tipo incriminador do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram claramente a materialidade do delito narrado na denúncia, bem como que o réu é seu autor.

Houve realmente a prática de crime de tráfico de entorpecentes, cuja materialidade restou confirmada pelo Auto de prisão em flagrante (fl. 04), Boletim de ocorrência (fls. 10/13), Auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), Laudo de constatação (fls. 34/36), Relatório final de inquérito policial (fls. 41/42), Laudo definitivo de exame químico-toxicológico (fls. 103/105), bem como pela prova oral colhida em juízo.

Com efeito, o laudo definitivo de exame químico-toxicológico nº 476.276/2016 (fls. 103/105) revelou resultado positivo para as substâncias cocaína (Itens A e B) e tetrahydrocannabinol, popularmente conhecida como maconha (Item C).

A autoria também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

Ao ser ouvida em juízo, a testemunha Flavio Alves Nunes, policial militar, narrou, em síntese, que estavam em patrulhamento de força tática pela via dos fatos, ponto já conhecido pelo tráfico de entorpecentes. Deparam-se com um indivíduo saindo do beco que tentou empreender fuga. Conseguiram realizar a abordagem e com ele encontraram um estojo escolar com entorpecente e valor em espécie. A princípio tentou usar de força física para impedir a abordagem. Salvo engano, foram apreendidas 21 porções de cocaína, 17 de crack e 54 de maconha. Quando chegaram foi possível visualizar a entrega de algo para uma pessoa em um veículo. O réu tentou fuga, mas não conseguiu.

Também foi ouvida em juízo a testemunha Jailton Francisco Marques, policial militar, que relatou, em suma, que na época fazia parte da força tática e estavam no patrulhamento. O local é conhecido para tráfico de drogas. Rafael estava no beco e ele tentou correr. Com ele tinha um estojo com várias porções de maconha, cocaína e crack e uma quantia em dinheiro em notas fracionadas. O estojo estava na mão do réu. Ele tentou correr dois, três metros. O réu falou que estava vendendo as drogas.

Ao ser interrogado em juízo, o réu confessou a prática delitiva. Em suma, o réu aduziu que está preso desde setembro de 2021. Sofreu condenação por roubo. Está com 33 anos de idade. Estudou até a oitava série. Na época do delito destes autos morava com a mãe. Naquela noite, realmente aconteceu, estava passando necessidade, precisava pagar pensão, estava com as drogas guardadas na viela, no beco. A droga estava dentro do estojo.

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, oitava edição, Editora Atlas, pág. 469: "(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos".

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição 2007, pág. 411: "A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia".

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais militares foram coesos e merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defensoria Pública não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Neste sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (RT 616/286-7).

Outrossim, pequenos desencontros nos depoimentos que não sejam em torno do principal não tem o condão de afastar a prática delitiva e tendem a indicar a inexistência de complô acusatório.

Desta forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais militares quanto à apreensão dos entorpecentes, não é lícito presumir que queiram prejudicar o acusado, pois agem em prol da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

A finalidade de narcotraficância foi perfeitamente evidenciada por alguns indícios irrefutáveis: a) pela natureza e variedade das drogas apreendidas (cocaína, crack e maconha); b) pela considerável quantidade de drogas (146,7g no total), incompatível com a condição de mero usuário; c) pela forma de acondicionamento das drogas apreendidas (em invólucros); d) pela apreensão de R\$ 39,00 (trinta e nove reais) em espécie; e) pelas circunstâncias da prisão. Todos esses fatores são indicativos do destino para consumo de terceiros.

Pelo que se vê, todos os elementos de prova complementam-se, formam um conjunto coeso e robusto no sentido de que o réu trazia consigo as drogas que foram apreendidas para o fim de comercializá-las, sendo certa a ocorrência do tráfico de entorpecentes, assim como a autoria. Assim, inadmissível seria a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006.

Assim, todas as provas colhidas não dão margem para outra conclusão senão a demonstração da materialidade do delito narrado na denúncia, bem como a sua autoria.

Passo à aplicação da pena com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em primeira fase, verifico que o réu deve ser considerado primário nestes autos, de crime cometido na data de 19/10/2016, conforme se infere da folha de antecedentes as fls. 172/175 e certidão as fls. 176/178. No mais, a culpabilidade do réu não ultrapassa o normal desvalor do tráfico de drogas, cometido em circunstâncias que não se mostram exageradas. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena-base no mínimo legal, partindo de 5 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a circunstância atenuante da confissão espontânea, mas deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal por ser entendimento jurisprudencial que as circunstâncias atenuantes não podem acarretar pena aquém do mínimo legal. Nesses termos é o teor da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

Em terceira fase, aplicável a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do mesmo artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. No caso em tela, à época réu primário, bem como nada indicando que integre organização criminosa, de modo que estão presentes as circunstâncias previstas no parágrafo 4º do citado artigo 33 da Lei que, somadas às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, autorizam a redução máxima da pena prevista no preceito secundário do caput do artigo 33. Sendo assim, aplicando a causa de diminuição já mencionada, reduzo a pena base de 2/3 (dois terços), chegando ao resultado de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Do regime inicial de cumprimento da pena

Tendo em vista a primariedade e a quantidade de pena aplicada, fixo o regime inicial aberto para início de cumprimento da pena. Com efeito, o Colendo Supremo Tribunal Federal afastou a hediondez do tráfico privilegiado (STF, HC nº 118.533). No caso concreto, mostra-se razoável e recomendável o regime mais brando. Isso porque o réu à época primário, sem ligação comprovada com organização criminosa ou lucro pessoal relevante.

Vem a lume trecho de elucidativo julgado do Superior Tribunal de Justiça, Habeas

Corpus nº 155.391 - ES (2009/0234881-9). Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Data do Julgamento 02 de setembro de 2010. Ementa:

"(...) A Sexta Turma desta Corte adotou o entendimento de que, ante o quantum de pena aplicado ao delito cometido sob a égide da Lei n.º 11.343/06, é possível a fixação do regime semiaberto ou o aberto para o início do cumprimento da reprimenda reclusiva, em conformidade com o previsto no art. 33 do Código Penal, bem como da substituição da pena de reclusão por restritivas de direitos, em face do artigo 44 do Código Penal. (...)". (grifos nossos)

E, conforme já decidiu o Excelso Pretório:

"Ementa. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dezesesseis gramas de cocaína e trinta e nove gramas de maconha. Crime praticado na vigência das Leis nºs 11.343/06 e 11.464/07. Aplicação da causa de diminuição em grau máximo. Possibilidade. Estabelecimento de regime prisional diverso do fechado. Possibilidade. Reprimenda inferior a quatro anos, reconhecimento da primariedade e ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Comando legal que deve ser compatibilizado com os princípios da individualização da pena e proporcionalidade. Substituição da sanção corporal por restritivas de direitos. Viabilidade. Precedentes do STJ e STF." (HC 168679/SP (2010/0064405-4). Relator Ministro OG FERNANDES. Órgão Julgador - SEXTA TURMA. Data do Julgamento 05/08/2010. Data da Publicação/Fonte DJe 23/08/2010). (grifos nossos)

Diante da quantidade de pena aplicada e da primariedade do réu, cabível a concessão dos benefícios previstos no artigo 44 e seguintes do Código Penal. Assim, tratando-se de pena superior a um ano, a pena privativa de liberdade será substituída por restritivas de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, à razão de uma hora de serviço por dia de condenação, em entidade a ser indicada por ocasião da execução e, em outra pena de prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo, que se somarão à pena de multa originária, com fundamento no artigo 44, §2º, e artigo 46, ambos do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e considerando tudo o mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a ação penal, para CONDENAR o acusado RAFAEL MARQUES DA SILVA, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe por isso a pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, da forma anteriormente especificada, além da multa originária no valor de 166 dias-multa, já prevista no tipo penal, calculados pelo valor unitário mínimo.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando a fixação do regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar o equivalente a 100 (cem) UFESPs, com as ressalvas do artigo 12 da Lei de Assistência Judiciária.

Com fulcro no artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal e do artigo 63, §1º da Lei Federal nº 11.343/2006, decreto o perdimento do valor retratado à fl. 40 (R\$ 39,00) em prol do Fundo Nacional Antidrogas - Funad, em nome da Secretaria Nacional Antidrogas. Oficie-se para encaminhamento do valor após o trânsito em julgado.

Ocorrido o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "rol dos culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 21 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA